

刑法
No273

H18-9

(配点：2)

月	日
月	日

学生AとBは、窃盗罪の保護法益について、「所有権その他の本権である。」とする見解と「占有それ自体である。」とする見解のいずれか異なる見解を採り、次の【事例】Ⅰ及びⅡの甲の行為が窃盗罪の構成要件に該当するか否かを議論したところ、学生Aは【事例】ⅠとⅡで結論が異なったが、学生Bは結論が一致した。各見解に関する後記の【記述】1から5までのうち、正しいものはどれか。

【事例】

- I. 甲は、その所有するカバンを乙に窃取されたが、その数時間後、偶然、街中で乙を見付け、同人からそのカバンを奪った。
- II. 甲は、乙が所有者丙から賃貸借契約により借り受けているカバンを、乙から奪った。

【記述】

1. 学生Aの採る見解は、Ⅰの事例の甲の行為について、自救行為として違法性が阻却されるから不可罰であると解することになる。これに対し、学生Bの採る見解は、窃盗罪の構成要件該当性を欠くから不可罰であると解することになる。
2. 学生Aの採る見解は、「事実としての財産的秩序」を保護しようとするものである。これに対し、学生Bの採る見解は、「私法上の正当な権利関係」を保護しようとするものである。
3. 学生Aの採る見解は、窃盗罪は「他人の財物」を客体とする犯罪であるから、自己の所有物が窃盗罪の客体となることを定めている刑法第242条は例外を定めた規定であると解することになる。これに対し、学生Bの採る見解は、同条は当然のことを定めた注意的な規定であると解することになる。
4. いずれの見解も、無関係な第三者が窃盗犯人の所持する盗品を奪った場合のその第三者の行為が窃盗罪の構成要件に該当するとするが、学生Aの採る見解が、この結論は、窃盗犯人の占有を侵害したから当然であると解するのに対し、学生Bの採る見解は、この結論は、窃盗犯人が一度侵害した所有者の所有権をその第三者が再度侵害するからであると解することになる。
5. 最高裁判所の判例の考え方は、学生Bの採る見解と異なり、学生Aの採る見解と同じである。

(参照条文) 刑法

第242条 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。

No273

窃盗罪の保護法益

正答率

H18-9

正解

3

91%

【学生の採る見解について】

学生AとBは、窃盗罪の保護法益について、「所有権その他の本権である。」とする見解（本権説）と「占有それ自体である。」とする見解（所持説）のいずれか異なる見解を採る。

そして、本権説は、所有権その他の私法上の本権の認められる財産のみが法益だとするのに対し、所持説は、事実上の支配、すなわち所持そのものがひとまず保護されるべきであるとし、最終的に民法等の法的権原に基づかない場合でも財産犯の成立を認める。

事例Ⅰでは、甲はカバンの所有権者であるため、本権説からは甲の行為は窃盗罪（235条）の構成要件に該当しない。他方、甲は乙の占有を侵害しているため、所持説からは甲の行為は窃盗罪の構成要件に該当する。

事例Ⅱでは、甲は乙の賃借権という所有権以外の本権を侵害しているため、本権説からは甲の行為は窃盗罪の構成要件に該当する。また、甲は乙の占有を侵害しているため、所持説からは甲の行為は窃盗罪の構成要件に該当する。

したがって、事例Ⅰと事例Ⅱで結論が異なった学生Aは本権説を採り、結論が一致した学生Bは所持説を採ることが分かる。

【記述について】

1 誤っている

学生Aの採る見解（本権説）は、Ⅰの事例の甲の行為について、窃盗罪の被害者である所有権者等が、犯人から盗品を取り戻す行為は、窃盗罪の保護法益を侵害するものではなく、窃盗罪の構成要件該当性を欠くから不可罰であると解することになる。これに対し、学生Bの採る見解（所持説）は、他人の占有する財物である限り、その占有が適法である与否を問わず、所有権者自身も自救行為その他の適法な方法による場合のほか、みだりにこれを侵すことは許されない。よって、乙の占有を侵害した甲の行為は窃盗罪の構成要件に該当するが、自救行為として違法性が阻却されるから不可罰であると解することになる。

2 誤っている

学生の採る見解についての解説で述べたとおり、学生Aの採る見解（本権説）は、「私法上の正当な権利関係」を保護しようとするものである。これに対し、学生Bの採る見解（所持説）は、「事実としての財産的秩序」を保護しようとするものである。

3 正しい

学生Aの採る見解（本権説）は、窃盗罪は（「他人の所持する財物」ではなく）「他人の財物」を客体とする犯罪であるから、自己の所有物が窃盗罪の客体となることを定めている242条は例外を定めた規定であると解することになる。これに対し、学生Bの採る見解（所持説）は、同条を素直に読めば、他人の占有するもの一般を含んでいるということにならざるを得ないとし、同条は当然のことを定めた注意的な規定であると解することになる。

4 誤っている

無関係な第三者が窃盗犯人の所持する盗品を奪った場合、本権説からは、窃盗犯人の占有が権原に基づかない以上構成要件に該当しないとも考えられる。しかし、本権説の論者はほぼ例外なく構成要件の充足を認め、また、所持説からも、他人の占有侵害がある以上構成要件を充足する。よっ

て、いずれの見解も、無関係な第三者が窃盗犯人の所持する盗品を奪った場合のその第三者の行為を窃盗罪の構成要件に該当するとする。よって、本記述の前段部分は正しい。しかし、学生Aの採る見解（本権説）が、このような結論を採るのは、窃盗犯人が一度侵害した所有者の所有権をその第三者が再度侵害するからであると解することによる。つまり、本権説からは、侵害されるのは窃盗犯人の裸の占有ではなく所有者の所有権であり、その第三者は一度侵害された所有権をさらに侵害するから可罰的だという説明がなされる。これに対して、学生Bの採る見解（所持説）は、この結論は、窃盗犯人の占有を侵害したから当然であると解することになる。つまり、所持説からすれば、他人の占有侵害がある以上、その第三者の窃盗罪は容易に説明し得る。したがって、本記述は、学生Aと学生Bの採る見解が逆になっている点で後段部分は誤っている。

5 誤っている

最高裁判所の判例の考え方は、財産犯においては「社会秩序を維持する必要からして、物の所持という事実上の状態それ自体が独立の法益として保護せられ」るべきであるとして、学生Aの採る見解（本権説）とは異なり、学生Bの採る見解（所持説）と同じである（最判昭24.2.15）。